

1500644-49.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500644-49.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500644-49.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julian da Silva Paes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. JULIAN DA SILVA PAES, qualificado a fls. 10, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 7 de agosto de 2022, por volta das 14h30min, na Avenida 23, cruzamento com a Rua 36, nº 1.557, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nas imediações de quadra poliesportiva e de academia ao ar livre, nesta cidade e Comarca de Guaiara, teria trazido consigo, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, cinquenta e quatro eppendorfs contendo, no total, 10,900 g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que “policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Vila Aparecida quando, no cruzamento da Avenida 25 com a Rua 36, avistaram JULIAN, pessoa conhecida pela prática do tráfico de drogas, em local também conhecido por tal atividade.

O denunciado, ao avistar a viatura policial, pegou sua bicicleta e cruzou, pela diagonal, a praça, oportunidade em que a viatura foi ao outro lado da praça para abordá-lo, mas JULIAN, percebendo tal movimentação, voltou ao local inicial. A viatura policial, porém, continuou tentando se aproximar do denunciado, ocasião em que, cansado, JULIAN foi para o outro lado da via pública, em direção a um terreno, e, repentinamente, deixou sua bicicleta e se jogou ao chão, gritando por populares e solicitando que o filmassem.

Em revista pessoal, os policiais encontraram no bolso esquerdo dianteiro do denunciado uma sacola branca com as drogas acima descritas em seu interior. No outro bolso, os agentes públicos apreenderam a quantia de cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos.”.

A denúncia de fls. 135/137 foi recebida em 5 de setembro de 2022 (fls. 139), sendo o Réu citado (fls. 154), apresentando defesa preliminar (fls. 159/160), rejeitada a fls. 163/164. Durante a instrução, foi colhida prova oral e interrogado o Acusado (fls. 240).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 238/239).

A douta Defesa, por seu turno, sustentou ausência de prova, se batendo pela absolvição e, subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para aquele tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas, posto que o Réu seria usuário de entorpecente (fls. 241/243).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/07, boletim de ocorrência de fls. 08/09, auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelo laudo de constatação provisória de fls. 13/15, no comprovante de depósito de fls. 125, pelo relatório de investigação de fls. 126/129, no laudo de exame químico-toxicológico a fls. 130/131, além da prova oral colhida durante a persecução.

A autoria é certa contra o Réu que, na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 04), ao passo que em Juízo negou o teor da denúncia, sustentando ser usuário de álcool e crack e na data dos fatos tinha recebido seu salário de marceneiro e foi até o local, ponto de venda de droga, sendo que conversava com uma garota de programa quando os policiais chegaram, querendo saber quem tinha fugido. Com ele somente encontraram uma pedra de crack e um cachimbo, que não foram apreendidos, negando que estivesse com aquele entorpecente descrito na denúncia, declarando, ademais, que não faz uso de cocaína, nas proximidades há uma quadra abandonada e

quinze dias antes de ser preso policiais militares teriam ido na casa de sua irmã, onde estava abrigado, não o encontrando, mas vindo a ameaça-lo. Ademais, já foi internado e saiu de uma clínica há cerca de quatro meses.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que o Réu nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois ele “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

Sua versão não se sustenta e deveria ser por ele comprovada.

Pois bem.

O policial militar Deivid, na fase judicial, declarou que durante o patrulhamento encontraram o Réu em conhecido ponto de venda de drogas e ele, ao avistar a viatura, empreendeu fuga de bicicleta, sendo perseguido e abordado, jogando-se ao chão, se debatendo e gritando e, em busca, localizaram em um bolso as cinquenta e quatro porções de cocaína e em outro dinheiro em notas diversas. Ademais, o Réu é conhecido dos meios policiais pelo tráfico, não aparentava estar sob efeito de drogas e no local há uma escola, além de quadra e academia ao ar-livre. Na mesma linha foi o depoimento do policial Renan.

Note-se que nada há nos autos a evidenciar que as testemunhas visassem imputar falsamente ao Réu uma conduta criminosa.

O comportamento do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local tinha em depósito substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente porque ele negou ser usuário de cocaína, no fato de ser conhecido dos meios policiais pelo tráfico, estar em notório ponto de traficância, tentar fugir ao avistar a viatura e a localização, em suas vestes, de considerável quantidade de cocaína (da qual ele declaradamente não faz uso) e dinheiro trocado, sem origem lícita, não podendo se ignorar, outrossim, que ele não estava sob efeito de entorpecentes. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006, inviabilizando por completo o pedido de desclassificação formulado pela douta Defesa para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Importante destacar que o simples fato de ser usuário de drogas – sequer comprovado – não inibiria a conduta do narcotráfico, sendo que, muitas vezes, tais condutas caminham juntas.

Dessa forma, considerando o quadro posto, certa a procedência da ação penal. Oportuno salientar que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo por que não podem ser descartados. A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o

princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão: "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória ou mesmo que não há prova de que o Réu concorreu para a infração, sendo que prova da mercantilização não é necessária para a prática do crime, quando presentes os requisitos comprobatórios do tráfico, como na hipótese em julgamento. Oportuno salientar, neste panorama, que "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

De outro modo, é forçoso se reconhecer que o Acusado traficava nas imediações de uma quadra poliesportiva e academia ao ar-livre (fls. 126/129 e da prova oral colhida em Juízo). Assim, perfeitamente caracterizada a causa de aumento de pena tipificada no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Destarte, passo a dosimetria da pena em relação ao tipo do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do Réu ou extingam a punibilidade.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado é portador de péssimos antecedentes demonstrando, assim, ter personalidade persistente na prática de condutas antissociais (cf. fls. 59/60, autos nº 0000642-81.2007.8.26.0210, fls. 61, processo nº 0001899-97.2004.8.26.0210, fls. 64/65, processo nº 0002449-92.2014.8.26.0210 e fls. 66, autos nº 0004769-23.2011.8.26.0210), que podem ser consideradas nesta fase, sem risco de provocar bis in idem com a agravante da reincidência, porque se tratam de processos diversos. Assim, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, onde verifico que deve sua pena-base deve ser majorada em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a no patamar de 5 anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aumento-a em 1/2 (metade) em razão da multirreincidência, inclusive específica (cf. fls. 59, autos nº 3003897-09.2013.8.26.0073; fls. 60/61, processo nº 0001874-79.2017.8.26.0210 específica; fls. 63, processo nº 0002182-18.2017.8.26.0210), atingindo o patamar de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa.

Em vista da incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, posto que se comprovou que ele vendia os entorpecentes nas imediações de

uma quadra poliesportiva, majoro sua pena em 1/6 (um sexto), à míngua de critérios que indicassem possibilidade de se aumentar a pena acima da fração mínima, e a fixo em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.019 (um mil e dezenove) dias-multa, em seu piso legal.

Sendo multirreincidente e portador de péssimos antecedentes, o Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que não há prova de ocupação lícita, além do fato de ser conhecido dos meios policiais pelo tráfico, crime equiparado ao hediondo, demonstrando que se dedica, exclusivamente, à atividade criminosa do comércio de drogas, muito embora alegue que trabalhava, uma vez que nem mesmo trouxe início de prova a este respeito. Dessa maneira, torno aquela pena definitiva, ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Importante consignar que caberia à defesa a prova de que o Acusado faria jus à causa de diminuição acima mencionada, considerando-se que esta não é automática e somente de aplicação possível quando presentes os requisitos legais, forte no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, ou seja, "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer". Desta forma, o Réu deveria indicar, através de provas robustas que trabalhava e não se dedicava a atividades criminosas, afastando o quanto foi comprovado pela acusação, isto é, que estava em ato de traficância.

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado a hediondo e ser o Réu portador de maus antecedentes e reincidente, é o inicial fechado. Por outro lado, é vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis, pela ausência do requisitos objetivo e subjetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Saliento, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada ao crime hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a

natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu, depositados em Juízo (fls. 125), que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o Réu JULIAN DA SILVA PAES, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.019 (um mil e dezenove) dias-multa, em seu piso mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda do dinheiro apreendido com ele, depositado a fls. 125, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e encaminhe-se o numerário apreendido a fls. 125 em favor da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo porque mantenho sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada justificando que, preso em flagrante, fosse posto em liberdade depois de condenado por crime equiparado ao hediondo, em especial diante de seus maus antecedentes.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA